



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Paulo Henrique Magalde Teixeira e Gabriel Pereira

Araújo, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, *caput*, e 35, *caput*, da Lei nº 11.343/06, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo consta, no dia 20 de dezembro de 2016, na Rua Francesco Solimena, 49, pela manhã, os acusados, associados entre si e com o adolescente Kaynã G.D.F., cuja corrupção favoreceram, traziam consigo, para fins de tráfico, 80 porções de maconha, 57 de cocaína, 37 de haxixe, 1 de skank e 7 de *crack*.

Determinada a notificação dos réus (fls. 108), houve resposta (fls. 150) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 151). Em audiência foi colhida a prova oral e os réus interrogados, tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 163/165.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação quanto ao delito de tráfico é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

De fato, ambos os policiais confirmaram que encontraram os réus e o adolescente num local conhecido de tráfico, tendo eles tentado fugir mas sido detidos, sendo encontrados com os réus o entorpecente, e com o menor anotações de contabilidade do tráfico.

E não há nada de concreto nos autos contra os policiais ouvidos, nem a indicação de qualquer razão que teriam para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando ao réu, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado, inexistindo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão.

Por outro lado, a negativa do réu Gabriel restou absolutamente isolada nos autos, sem nenhum elemento que a corrobore, carecendo de qualquer credibilidade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Já o réu Paulo admitiu a prática do tráfico, com o adolescente, só não incriminando o corréu Gabriel, o que pode até ser compreendido, ante o fato de estarem presos juntos, sendo certo que pode temer represálias caso delate seu comparsa.

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão dos réus (especialmente a quantidade e forma de acondicionamento em porções separadas, além da variedade de substâncias) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

De rigor, assim, a condenação de ambos pelo crime de tráfico.

E a prática com o adolescente, igualmente certa, já que este portava as anotações de controle da venda, implica na incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, esta a norma específica, e não do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, havendo aqui mera correção da tipificação, já que os fatos estão descritos na denúncia, prescindindo de qualquer aditamento.

Já, quanto ao delito de associação, nada indicando que os réus atuavam juntos antes, em outras circunstâncias, havendo a prova apenas do mero concurso no dia da prisão, não resta comprovado o delito autônomo.

Assim, certa a condenação pelo artigo 33, *caput*, c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tenho que é necessária a fixação da pena base bastante acima do piso legal.

O que indica a maior gravidade do delito, e recomenda uma exasperação da pena, é justamente a natureza e quantidade das substâncias apreendidas. Diversas são as substâncias que caracterizam entorpecentes. Contudo, dentro dessas, há algumas que são mais graves, seja por terem maior poder de gerar dependência, seja por serem mais nocivas ao organismo do usuário.

Não há dúvidas de que a cocaína causa dependência com muito mais facilidade que a maconha, assim como gera maiores consequências para o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

organismo do usuário. Já o *crack* ou a heroína são ainda muito piores, causando forte vício a partir de poucas utilizações e sendo extremamente nocivos à saúde do usuário.

Embora todas sejam substâncias entorpecentes submetidas à Lei de Tóxicos vigente, não se pode negar que possuem características, seja quanto ao grau de dependência, seja quanto à nocividade, muito diferentes entre si, não podendo ser consideradas de forma absolutamente indistinta na dosimetria da pena correspondente, justamente porque não se pode dar o mesmo tratamento a quem comercializa uma substância extremamente nociva e viciante em relação a outra pessoa que repassa outra substância muito menos danosa, dado que são condutas que atingem de forma diversa os usuários e a própria sociedade.

Assim, em sendo o delito de tráfico de substância mais grave, a pena a ser aplicada, para quem explora o vício e gosto dos usuários, deve ser maior.

E não é demais lembrar que, quanto mais forte a dependência gerada pela substância, mais crimes serão cometidos para sustentar o vício dos dependentes, implicando assim, como dito, numa maior gravidade não só para quem usa o entorpecente, mas sim para toda a sociedade.

Desta forma, tenho aplicado para o tráfico de maconha, droga esta menos nociva, a pena no mínimo legal. Já para o tráfico de cocaína, aumento esta pena e, em se tratando de *crack*, como havia no presente caso, aplico um aumento ainda maior, posto que a destruição nas vidas dos usuários desta substância, explorada pelo traficante, é muito maior.

Note-se, ademais, que no presente caso os réus tinham uma ampla e poucas vezes vista variedade de drogas, envolvendo maconha, *crack*, cocaína, skank e haxixe, o que denota sofisticada e intensa imersão dos réus no âmbito do tráfico, o que não pode ser desconsiderado.

Mas, além disso, há que se observar a considerável quantidade de entorpecente apreendida, totalizando 180 porções, podendo atingir um enorme número de usuários. Não se pode, portanto, punir este delito da mesma forma que se tivesse sido apreendido com os réus apenas uma dúzia de porções, por exemplo.

Assim, no caso dos autos, aumento a pena base dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

réus em dois anos e 200 dias-multa acima do mínimo na fase do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, pela atenuante da confissão de Paulo, reduzo sua pena em um sexto.

Já, para Gabriel, pela reincidência (fls. 134), elevo suas penas em um sexto.

E os réus não fazem jus ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Em primeiro lugar, observo, como dito, a sofisticada forma de atuação deles, envolvendo ampla variedade de tipos de droga, e controle de contabilidade, tudo denotando profunda imersão no tráfico, e não uma ação isolada e ocasional, que justificasse o benefício.

E note-se que, conforme pesquisa juntada, e confirmado pelo réu, Paulo havia sido preso por tráfico no mesmo local apenas 20 dias antes de ser preso por estes autos, o que confirma ser ele pessoa profundamente voltada à prática de tal crime, não tendo aquela prisão o dissuadido de vir a praticar o crime dos autos.

Além disso, de se notar também a reincidência de Gabriel, que também veda o redutor.

E não há nisso nenhum *bis in idem*, mas tão somente a não satisfação pelos réus dos requisitos, bastante razoáveis, estabelecidos pelo legislador para um benefício que é excepcional, voltado àquela pessoa que tenha tido um envolvimento absolutamente isolado e ocasional com tal prática criminosa, sem maior gravidade, e merecedor de um tratamento diferenciado. E nesse sentido da validade dos requisitos legais para tal benefício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. AGENTE REINCIDENTE E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS EFEITOS PRÓPRIOS DO INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Constatando-se a ocorrência da reincidência, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra, qual seja, ser o agente primário.

2. Não há o que se falar em bis in idem, mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico - a reincidência - quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente.

3. Ademais as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do agente, somadas à quantidade e à diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas em seu poder, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa.

(...)

(HC 242.769/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.

3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica.

4. Ordem denegada.

(HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012)

Presente a causa de aumento de pena da prática com menor, e sendo certo que este tinha apenas 15 anos de idade quando dos fatos (fls. 13), mas foi envolvido pelos réus neste sofisticado tráfico, é de rigor o aumento das penas, que faço em um quarto, já que o piso de um sexto seria reservado à hipótese de envolvimento de um adolescente já com 17 anos de idade, e num tráfico de menor gravidade.

Por tudo isso, restam as penas dos réus em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 1020 dias-multa, no piso, para Gabriel, e em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 728 dias-multa, no piso, para Paulo.

Ante as circunstâncias severamente negativas acima indicadas, observando ainda a natureza do delito e o total das penas, o regime inicial não poderá ser outro que não o fechado, sendo descabida a substituição da pena ou o sursis.

E, pelas mesmas razões, tendo os réus respondido ao feito custodiados, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a suas custódias cautelares, especialmente observando a pena aplicada e as circunstâncias desfavoráveis acima indicadas, que denotam serem pessoas voltada à prática deste tipo de delito, não há razão para o reconhecimento de situação excepcional que justificasse o direito de apelar em soltos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Isto posto, julgo a presente ação **PARCIALMENTE PROCEDENTE**, para condenar **Paulo Henrique Magalde Teixeira e Gabriel Pereira Araújo**, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, às pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e 1020 dias-multa, no piso, para Gabriel, e de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 728 dias-multa, no piso, para Paulo, sendo para ambos o regime inicial fechado, observada a progressão diferenciada. E **ABSOLVO-OS** da imputação no art. 35, *caput*, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os réus **não** poderão apelar em liberdade, nos termos *supra*.

Expeçam-se ofícios de recomendação.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, **oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.**

Custas pelos condenados, na forma do artigo 4º, § 9º, *a*, da Lei nº 11.608/03, ressalvada eventual inexigibilidade em caso de pobreza, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, que fica presumida pela atuação da Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, **16 de março de 2017.**

Juiz de Direito: Dr. **Carlos Eduardo Lora Franco**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ciente:

Ministério Público:

Réu(s):

Defensor(es):